

1501906-44.2021.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... notícias de que o réu praticava tráfico há cerca de um mês antes da data da prisão.

Interrogado, o réu assumiu a propriedade da droga, negando o tráfico. Disse que "guardava" a droga nesse terreno próximo a sua casa. Estava com uma faquinha de serra para "dichavar" a maconha, pois não tinha o "dichavadorzinho". Havia comprado a droga há poucos dias e o terreno ficava a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501906-44.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501906-44.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215746/2021 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA, 19527689 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 29/21/118 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA, 2215746 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS FELIPE SANTOS OLIVEIRA

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra LUIS FELIPE SANTOS OLIVEIRA imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 13 horas, na Rua José Castanheira Pedrosa, nº 310, Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.09 e 20/22 dos presentes autos, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 porções de "maconha", com peso aproximado de 91,08g (cf. autos de constatação provisórios de fls.12/15 e 16/19), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2021, em fls.77/80. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.127/131.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação da conduta ou aplicação do redutor do § 4º.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls. 01/03; boletim de ocorrência de fls. 04/06; termo de depoimentos de fls. 07/08; auto de exibição/apreensão de fls. 10/11; termo de interrogatório de fl. 09; fotografia de fl. 39; laudos periciais de fls. 121/122 e 123/125, além do relatório de fl. 186), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

Argemiro Dantas Costa Júnior, policial militar, narrou que recorda-se que estavam em patrulhamento e receberam informação de uma pessoa falando que um tal de "Felipe", trajando camisa de time de futebol de cor vermelha, estaria negociando, via Whatsapp, a venda de droga na rua José Castanheira Pedrosa. Foram ao local e se depararam com o Felipe saindo do quintal de uma casa; ele dispensou algo ao solo. Foi abordado. Com ele havia um aparelho celular, uma quantia em dinheiro e uma faca, com resquícios de maconha. Fizeram a vistoria próximo ao local e localizaram 3 invólucros de maconha em plástico. Ele alegou ser usuário. Mais para frente havia outra porção, com um peso maior, um tijolo pequeno in natura. Ele também reconheceu como sendo dele. O dinheiro estava em notas diversas, que ele alegou que havia trocado num bar. Deram voz de prisão e conduziram à DISE. Não conhecia o Felipe dos meios policiais.

A testemunha de defesa Mayara Stefani Matias, esposa do réu, falou que ele fazia bicos com o pai dele, sendo esta a origem do dinheiro. Ele é usuário de droga e já foi demitido por justa causa da Friboi por uso de maconha. Disse que o réu nunca trouxe dinheiro sem origem para casa. Ele também nunca trouxe drogas para casa. Falou que ele guardava a droga no terreno baldio no fundo da casa, onde foi preso. Relatou que ele usava drogas fora de casa e que usava "muita droga".

A testemunha de defesa Dioni Candido dos Santos relatou que já foi amigo do réu, mas se afastaram por conta do uso de drogas por parte dele.

O também policial militar Willian Calister de Almeida esclareceu que estavam em patrulhamento quando ao se aproximarem do bairro foram solicitados por um senhor que passava pelo local e indicou que um indivíduo praticava tráfico, inclusive via WhatsApp. Depararam-se com o Felipe saindo de uma residência, a qual não é a dele, e que dá acesso a um pasto, terreno baldio. Ao notar a presença policial ele soltou algo de suas mãos e foi abordado. Com ele foi localizada uma faca com resquício de maconha. O que ele havia soltado ao solo eram porções de maconha prontas para o comércio. Ele confessou a propriedade da droga e disse que havia mais no pasto. Foram ao local e de fato apreenderam mais droga, cerca de 100 gramas ao total. Ele se disse usuário. Foram localizadas oito notas de R\$ 10,00 e duas notas de R\$ 5,00. Notas de 10 reais mais 2 de 5. Ele negou a traficância, dizendo que a droga era para consumo próprio. Questionado pelo MP disse que recebiam notícias de que o réu praticava tráfico há cerca de um mês antes da data da prisão.

Interrogado, o réu assumiu a propriedade da droga, negando o tráfico. Disse que "guardava" a droga nesse terreno próximo a sua casa. Estava com uma faquinha de serra para "dichavar" a maconha, pois não tinha o "dichavadorzinho". Havia comprado a droga há poucos dias e o terreno ficava a cerca de 20 metros de sua casa. Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese ocorreu a apreensão de mais de 90 gramas de maconha, logo após os policiais receberem notícia de um transeunte de que o réu estava praticando tráfico

no local, naquele momento. A quantidade de droga é expressiva. Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017), sendo a quantidade apreendida suficiente para centenas de cigarros.

A versão trazida pelo réu é absolutamente descabida. Pessoa não abastada, disse ter adquirido R\$ 400,00 de maconha apenas para seu uso e que guardava (!) a droga em um terreno próximo a sua casa. Para além da falta de praticidade (já que, toda vez que quisesse usar a droga teria de sair de casa e ir até o terreno, inclusive arriscando-se a ser flagrado), certo que a maconha é uma planta e, por isso mesmo, bastante perecível – deixar cerca de 90 gramas de planta ao relento faria com que rapidamente estragasse. Além disso, o alto valor do entorpecente torna completamente inverossímil a versão de que um terreno baldio localizado a 20 metros da casa do réu seria um local próprio para guardar a droga para o próprio consumo. Isto sem falar do risco de que valiosa "mercadoria" fosse perdida.

Não bastasse isso, o réu estava com uma faca, a qual é própria para cortar os tijolos de maconha prensada, mas não totalmente adequada para esfarelar a droga para o consumo imediato (a tal "dichavada" referida pelo réu em seu interrogatório).

Adicione-se o relatório de fl. 186, extraído do celular do réu, dando conta da negociação com outras pessoas, no dia anterior e no dia da própria prisão.

Assim, seja pela quantidade da droga, seja considerando-se o local e às condições em que se desenvolveu a ação, somadas aos depoimentos fidedignos dos policiais de que vinham recebendo notícias de que o réu praticava o crime, o tráfico é evidente.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário.

Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJ TJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima $\frac{1}{8}$ sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($\frac{1}{6}$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $\frac{1}{6}$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de $\frac{1}{8}$ (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o

intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO – 6ª Turma – julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base, pois a droga localizada não é de maior potencial lesivo e a quantidade será valorada na terceira fase.

Ausentes atenuantes ou agravantes.

A pena fica assim inalterada, no patamar mínimo.

Na terceira fase, sem oposição do Ministério Público, aplico o redutor em metade, considerando-se a quantidade de entorpecente, expressiva, especialmente para os padrões da Comarca.

Sendo assim, a pena fica em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e quantidade de droga (ainda que valorada na terceira fase) deve ser o intermediário, ou seja, o semiaberto. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena, que não seria recomendável às circunstâncias do caso, na forma do CP 44, III..

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO LUIS FELIPE SANTOS OLIVEIRA, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

Recurso em liberdade, devendo ser computado o tempo em que ficou preso quando do cumprimento da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 11 de fevereiro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)